

1501089-58.2022.8.26.0019

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Receptação

Magistrado: EUGENIO AUGUSTO CLEMENTI JUNIOR

Comarca: Americana

Foro: Foro de Americana

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 21/10/2022

... RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RÉU REINCIDENTE NA POSSE DE SIGNIFICATIVA QUANTIDADE DE DUAS ESPÉCIES DE ENTORPECENTES. INDICATIVOS DE PRÁTICA CONTINUADA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA EVIDENCIADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. (...). 2. Na hipótese dos autos, as instâncias ordinárias concluíram que o fato que ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Americana

Foro de Americana

2ª Vara Criminal

Avenida Brasil Sul, nº 2669, Americana-SP - cep 13468-390

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501089-58.2022.8.26.0019 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501089-58.2022.8.26.0019

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Receptação

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2126181/2022 - 02º D.P. AMERICANA, 24854706 - 02º D.P.

AMERICANA, 2126181 - 02º D.P. AMERICANA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GABRIEL RODRIGUES GEA e outros

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). EUGENIO AUGUSTO CLEMENTI JUNIOR

Vistos.

GABRIEL RODRIGUES GEA, CARLOS HENRIQUE BENTO DE OLIVEIRA e ALESSANDRO DA SILVA RODRIGUES FERRO, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso no artigo 155, § 1º e § 4º, incisos I e IV, do Código Penal, porque, na data e local descritos na denúncia, no período noturno, previamente ajustados e com unidade de desígnios, e mediante rompimento de obstáculo, subtraíram, para o proveito comum, coisa alheia móvel, ou seja, aproximadamente 30 (trinta) metros de fios elétricos, com peso aproximado de 80 (oitenta) quilos, pertencentes à Companhia Paulista de Força e Luz - CPFL.

A denúncia foi recebida em 30 de maio de 2022 (fls. 199/201).

Os réus foram citados, apresentando defesa (fls. 270/279, fls. 280/288 e fls.

289/297).

Na audiência de instrução e julgamento, foram ouvidas a vítima e as testemunhas arroladas, bem como os réus interrogados (fls. 366/367 e fls. 341/342).

O Doutor Promotor de Justiça (fls. 361/365), entendendo estarem suficientemente provadas a autoria e a materialidade do delito, requereu fosse a ação penal julgada procedente, com a conseqüente condenação dos réus pelo delito de furto qualificado.

A Doutora Defensora dos réus alegou matéria preliminar. E, no mérito, requereu a absolvição por falta de provas ou a desclassificação do delito (fls. 394/412).

Ante a alegação de matéria preliminar, os autos retornaram ao Ministério Público, o qual manifestou-se as fls. 420.

É, em síntese, o relatório.

DECIDO.

A preliminar de inépcia da denúncia, não deve ser reconhecida, tendo em vista que a prefacial atende os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal, não havendo que se falar em inépcia. Segundo o entendimento da jurisprudência: HABEAS CORPUS IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO A RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ANÁLISE DO MÉRITO. PRINCÍPIO DA OFICIALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO MAJORADO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E CORRUPÇÃO DE MENORES. REJEITADA PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS DO ART. 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. EVITAR REITERAÇÃO DELITIVA. PACIENTE COM DIVERSAS PASSAGENS CRIMINAIS E AÇÕES PENAIAS EM ANDAMENTO. PERICULOSIDADE SOCIAL. MEDIDAS CAUTELARES. INADEQUAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. (...). 2. Rejeitada a preliminar de inépcia da denúncia. Ao contrário do alegado, foram atendidos os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, tendo sido exposto o fato criminoso e suas circunstâncias, com a devida qualificação do recorrente e demais acusados, classificação do crime e indicação do rol de testemunhas. A tese de insuficiência das provas de autoria ou participação resume-se à alegação de inocência, a qual não encontra espaço de análise na estreita via do habeas corpus ou do recurso ordinário, por demandar exame do contexto fático-probatório. 3. (...). 7. Habeas corpus não conhecido. (HC 533.767/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 10/10/2019, DJe 21/10/2019)

DENÚNCIA - Requisitos do art. 41 do CPP - Prolixidade e luxo de pormenores - Desnecessidade: 62 - A exigência do Código de Processo penal, em seu art. 41, quando a exposição do fato criminoso com "todas as suas circunstâncias", não significa que a denúncia deva ser prolixa, contendo pormenores existentes nas peças do inquérito. RJDTACRIM VOLUME 23 JULHO/SETEMBRO/1994 PÁGINA: 134 RELATOR: - SILVA RICO.

DENÚNCIA - Atendimento aos pressupostos da Lei Processual Penal - Inépcia - Inocorrência: 216(a) - A denúncia onde se acha presente fato normal, atribuído a culpados, cumpre os reclamos da Lei Processual Penal, não podendo ser taxada de inepta. RJDTACRIM VOLUME 24 OUTUBRO/DEZEMBRO/1994 PÁGINA: 416 RELATOR: - SILVEIRA LIMA

DENÚNCIA - Ausência de descrição pormenorizada da participação de cada co-réu - Nulidade - Inocorrência: 279 - Inocorre nulidade da peça inicial, pelo fato do Promotor não descrever pormenorizadamente a participação de cada co-réu no evento criminoso, máxime quando tal atitude, em nenhum momento, impediu o réu de exercer sua defesa. RJDTACRIM VOLUME 23 JULHO/SETEMBRO/1994 PÁGINA: 486 RELATOR: - CANELLAS DE GODOY.

No mérito, a ação penal é procedente.

A materialidade do delito encontra-se demonstrada pelos autos de fls. 01/06, 07/13 e fls. 28/32, e laudos de fls. 251/258 e fls. 321/323.

A autoria é indubitosa.

Os réus foram presos em flagrante, que segundo Rafael Magalhães, apud Tourinho Filho "é a certeza visual do crime". A expressão também é usada na doutrina clássica por Tostes Malta, na obra *Do Flagrante Delito*, 1933, p. 25. De acordo com Hélio Tornaghi, prender em flagrante é capturar alguém no momento em que comete um crime. Ainda segundo o ilustre autor:

"Nunca é demais lembrar que a flagrância talvez seja a prova mais eloquente do crime e da respectiva autoria" (Curso de Processo Penal, 5ª ed., II/49).

De acordo com a jurisprudência, a prisão em flagrante implica indícios de autoria em desfavor do agente. Nesse sentido:

Furto - Tentativa - Suficiência probatória. Os elementos probantes amealhados nestes autos foram concludentes quanto à efetiva participação do recorrente na tentativa de furto, principalmente se levado for em consideração o fato de sua prisão em flagrante delito, transmutada na certeza visual do crime, sem esquecer-se, da robusta prova oral colhida, durante a instrução criminal. (Apelação nº 990.10.149887-1, Voto 20.894, da 14ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, Relator: WILSON BARREIRA, Data 02/09/2010)

PRISÃO EM FLAGRANTE - Prova - Certeza visual do delito que gera indícios de autoria em desfavor do agente - Entendimento:59(b) - A prisão em flagrante, por ser a certeza visual do delito, gera indícios de autoria em desfavor do agente. (Habeas Corpus nº 374.018/3, Julgado em 29/01/2.001, 12ª Câmara, Relator: Amador Pedroso (Presidente), RJTACRIM 52/205)

ROUBO MAJORADO. Apelação Criminal Ministerial. Condenação. Possibilidade. Vítima ouvida somente na fase extrajudicial. Irrelevância. Certeza visual do crime. Autoria comprovada pela prova oral. Recurso provido. (Apelação nº 0090593-47.2008.8.26.0050, da m 2ª Câmara Criminal Extraordinária do Tribunal de Justiça de São Paulo, Relator: EDUARDO ABDALLA, Data: 09/08/2013)

Na ocasião, os réus estavam na posse dos bens subtraídos. A apreensão do bem subtraído em poder do acusado implica em forte prova indiciária, nos termos da melhor doutrina (cf. FRANÇOIS GORPHE, "De la Apreciación de las Pruebas", tradução de Alcalá Zamora y Castillo, 1ª Ed., EJE, Buenos Aires, 1950, pág. 316; ERICH DÖRING, "La Prueba, su Practica y Apreciación", tradução de Tomás Banzhaf, 1ª ed., EJE, Buenos Aires, 1986, pp. 367-8; CAMARGO ARANHA, "Da Prova no Processo Penal", 3ª Ed., Saraiva, 1994, cap. XVI, ns. 2 e 8, págs. 166 e 175).

Nesse caso, cabe à Defesa o ônus de provar a origem lícita do bem. Não é diverso o entendimento da jurisprudência:

"APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. (...) 2. Ademais, 'em tema de delito patrimonial, a apreensão da coisa subtraída em poder do réu gera a presunção de sua responsabilidade e, invertendo o ônus da prova, impõe-lhe justificativa inequívoca', o que não ocorreu na espécie, pois o apelante não trouxe aos autos qualquer prova que demonstrasse a veracidade de sua versão. 3. (...)." (STJ - ARE 329.535/PI Rel. Min. Marilza Maynard - Desembargadora convocada do TJ/SE - 6ªT. DJE 25.08.2014)

ROUBO - materialidade - auto de apreensão e prova oral que indica a subtração mediante grave ameaça. ROUBO - autoria - depoimento de vítima indicando como autor - validade - depoimento policial que indica a apreensão da res furtiva em seu poder validade, só devendo o depoimento policial ser visto com reservas quando presente

indício que a acusação visa justificar eventual abuso praticado - a apreensão da res furtiva com o acusado inverte o ônus de prova e impõe à defesa demonstrar posse de boa-fé sob pena de ter-se por provada a autoria inteligência do art. 156 do CPP. (...) (TJSP - APL: 00087038720118260533 SP 0008703-87.2011.8.26.0533, Relator: Lauro Mens de Mello, Data de Julgamento: 04/12/2014, 8ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 10/12/2014)

“(...) é cediço que, em se tratando de delito patrimonial, a apreensão da "res" em poder do acusado gera a presunção de sua responsabilidade e, invertendo o ônus da prova, impõe-lhe justificativa inequívoca para o fato, sob pena dessa presunção se transmutar em certeza apta a ensejar o decreto condenatório (...)” (TJSP, 15ª Câmara de Direito Criminal, Apelação Criminal nº. 0078089-91.2010.8.26.0000, Rel. Des. Amado de Faria, j. 26.05.11);

PROVA - Furto - Apreensão da "res" em poder do agente - Presunção de responsabilidade - Entendimento: 31 (b) - Em sede de roubo, a apreensão da "res furtiva" em poder do agente gera a presunção de sua responsabilidade e, invertendo o ônus da prova, impõe-lhe justificativa inequívoca, sendo certo que, se esta for inverossímil a presunção se transmudara em certeza autorizando o desate condenatório. RJDTACRIM VOLUME 18 ABRIL/JUNHO 1993 PÁGINA: 66 RELATOR:- PASSOS DE FREITAS

A vítima/testemunha Diogo, representante da pessoa jurídica, disse que estava trabalhando no plantão da madrugada, e foi informado acerca do arrombamento e furto. Disse, ainda, que se dirigiu a Delegacia e verificou os cabos.

E a testemunha Henrique declarou que trabalha como vigilante na CPFL, e perto das 22h, e estava fazendo a ronda quando escutou um barulho, aparentando martelo. Informou que trata-se de lugar onde não é livre o acesso, e foi verificar, mas não visualizou ninguém, encontrando apenas um martelo e uma serra. Disse que por volta das 23h30min., apareceu no lugar uma viatura policial, avisando que prendeu indivíduos, e queria confirmar o local da subtração dos fios. Confirmaram, então, que as tampas das caixas de fios subterrâneos estavam abertas, os fios cortados, e visualizaram um rastro que levava para a área de mata, e linha do trem. Questionado, confirmou ser possível que, no período entre ter escutado o barulho e se dirigido ao local, os indivíduos tenham se evadido. Narrou que na primeira verificação as caixas subterrâneas estavam fechadas, apenas quando da vistoria com a polícia que estavam abertas, e os fios arrancados.

Não há nos autos prova de que a vítima/testemunha conhecia os réus anteriormente ou que tivesse intenção de prejudicá-los, atribuindo-lhes falsamente a prática de crime.

No mesmo sentido foi o depoimento dos policiais que atenderam a ocorrência e terminaram por deter os réus.

Os guardas municipais esclareceram que estavam em patrulhamento, perto da madrugada, quando avistaram três indivíduos, saindo de uma área verde, aos fundos da CPFL, arrastando fios elétricos e os colocando dentro de um veículo. Narraram que efetuaram a abordagem, sendo que Alessandro, o qual era o condutor, e Gabriel desceram do veículo, e Calos permaneceu no interior do automóvel, tentando se esconder. Com a chegada do apoio, em vistoria no veículo, localizaram os fios elétricos, uma lanterna, chave de fenda e faca. Deslocaram-se a estação da CPFL, fizeram contato com o vigilante, e verificaram o local da subtração, ou seja, duas caixas subterrâneas, com as tampas abertas, com os fios cortados, onde ainda se encontrava uma serra. Declararam, também, que o vigilante informou que escutou um barulho, por volta das 22h, efetuou a ronda, mas não viu ninguém. Indagados, os réus negaram a prática do delito de furto, sendo que Alessandro e Gabriel alegaram que os cabos já estavam cortados na CPFL, e apenas iriam levar a outro lugar, e

Carlos permaneceu em silêncio.

São irrelevantes as pequenas contradições da prova testemunhal, em razão das próprias imperfeições humanas, máxime quando as testemunhas concordam sobre pontos e circunstâncias essenciais. Segundo Borges da Rosa:

“Como dizem BINET, STERN, VARENDONCK, GORPHE, BANCELS e outros, os erros são elementos constantes na prova testemunhal; a testemunha não sujeita a erros não existe, porque o depoimento, o testemunho, é uma reprodução pessoal e lacunar da realidade. As divergências e contradições entre os depoimentos de duas ou mais testemunhas são, portanto, naturais; o que não é natural é a conformidade dos mesmos, que faz supor a identidade de inspiração, o concerto prévio, o eumdem premeditatum sermonem, de que fala FLAMARINO MALATESTA, na sua Lógica das Provas” (Comentários ao Código de Processo Penal, 3ª Ed., RT, 1982, pág. 322).

Assim sendo, pequenas divergências nos aspectos secundários, porém com coincidência nos essenciais, entre os relatos das vítimas e testemunhas não lhes retiram o valor probatório. Não é diverso o entendimento da jurisprudência:

Roubo simples tentado e ameaça – art. 157, caput, c.c. art. 14, II e art. 147, todos do CP Absolvição por insuficiência de provas Impossibilidade - Materialidade e autoria devidamente comprovadas. Robusto conjunto probatório (...) - Aliás, ao contrário do que alega a defesa, apesar de haver divergências entre os depoimentos das testemunhas, isto em nada altera a segurança com a qual elas narraram os crimes, tratando-se de pequenas discrepâncias normais que decorrem naturalmente da narrativa pessoal de cada depoente - (...). (Apelação Criminal nº 1509240-70.2019.8.26.0228, da 7ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, Relator: FREITAS FILHO, Data: 29 de janeiro de 2020)

Pequenas divergências entre os relatos das testemunhas - Irrelevância - Validade. 63 (b) - As pequenas contradições na prova decorrem das próprias imperfeições do psiquismo humano, agravadas, em geral, pelas condições em que a prova é realizada. Assim, de se desconfiar do testemunho demasiado perfeito, sendo, sim, importante, verificar se, embora discrepantes em detalhes mínimos, concordam os depoimentos nos pontos essenciais, quanto às circunstâncias decisivas do fato. RJDTACRIM VOLUME 6 PÁG.78 ABRIL/JUNHO/90 RELATOR:-JOSÉ HABICE.

O réu Gabriel, ouvido em Juízo, negou a prática do furto, declarando que foi contratado por “Esqueleto” para ir buscar alguma coisa, sendo que não sabia que era ilícito, e apenas no local verificaram que eram os fios. Questionado disse que conhece apenas por “Esqueleto”, o qual ofereceu, aos três, duzentos reais para buscarem algo, e aceitaram para comprar mais drogas. Negou que “Esqueleto” tenha ido até o local onde estavam os fios, perto da mata, onde, pouco após, foram abordados pelos policiais.

O réu Carlos, ouvido em Juízo, negou a prática do furto, declarando que estavam em uma praça quando passou uma pessoa conhecida por “Esqueleto” e perguntou se queriam ganhar duzentos reais para “carregar um negócio”, sem especificar o objeto. Disse, ainda que aceitaram, pois queriam comprar mais drogas, e com “Esqueleto”, foram até o local, e enquanto estavam carregando os fios, ele foi buscar o dinheiro, marcando ponto de encontro. Por fim, enquanto estavam carregando os cabos, os quais estavam no mato, foram abordados pela polícia, colocando os fios dentro do carro. Questionado, informou que “Esqueleto” dirigiu-se a Alessandro, ofertando o serviço, mas os três estavam no local, e disse que “Esqueleto” os levou até onde estavam os cabos, e depois foi para um posto de gasolina os aguardar.

E, o réu Alessandro, ouvido em Juízo, negou a prática do furto, declarando que apenas estava carregando os fios, pois foi chamado por “Esqueleto”, em um Uno vermelho, para “fazer um frete”, perto da meia-noite. Disse que os três estavam usando drogas, e foi oferecido duzentos reais pelo serviço, mas não sabiam o que seria transportado. Narrou que não precisou entrar na CPFL, pois os fios já estavam

na mata, sendo que os entregariam no Zanaga. Questionado, não soube identificar o “Esqueleto” e informou que ele foi até o local para mostrar onde deveriam pegar os fios, e depois saiu, dizendo que os pagaria na entrega no Zanaga. Por fim, estavam carregando os fios quando foram abordados pelos policiais. E, seu veículo já estava sem os bancos, por fazer fretes e recolher recicláveis.

Os argumentos trazidos pela defesa não foram suficientes para ilidir os fortes indícios e provas diretas contra os acusados, inclusive acerca das qualificadoras, tendo em vista a comprovação do concurso pelas declarações iniciais, reforçada pelas testemunhas.

Ainda, a qualificadora de rompimento de obstáculo encontra-se demonstrada pela prova testemunhal, de acordo com o artigo 167 do Código de Processo Penal, bem como pelo laudo de fls. 251/258, não havendo falar-se em qualquer afastamento de qualificadora.

Restou comprovado, portanto, que os réus deslocaram-se até o local com o intuito de praticar delito contra o patrimônio.

Não obstante as alegações da defesa, não é possível a absolvição do delito, o reconhecimento da exclusão das qualificadoras ou a desclassificação para receptação.

Assim, a versão pueril dos réus em juízo, ou seja, que apenas foram contratados para fazer o transporte de um objeto, com a ausência de conhecimento acerca da ilicitude, restou isolada no conjunto probatório. Até porque, não provada. É notório que no caso de invocação de alibi, inverte-se o ônus da prova, cabendo à parte que alegou demonstra-lo.

Há que se analisar as contradições posto que não foram capazes de identificar a pessoa que teria “contratado” o serviço, e, também, divergem em suas versões acerca da presença de tal pessoa no local onde os fios estavam.

No mais, há que se analisar que o vigilante indicou que perto das 22h escutou um barulho, mas as caixas subterrâneas não estavam abertas. E, logo após, ou seja, perto das 23h30min., os policiais já estavam com os réus apreendidos, e os bens foram constatados danificados.

Desta forma, o lapso temporal permite delimitar-se que, durante o espaço de tempo entre o primeiro ruído e a prisão, os réus, os quais possuíam no veículo ferramentas para tanto, arrombaram a fiação e a arrastaram pela área de mato até o veículo.

Não sendo crível as versões de que entre a “contratação” e deslocarem-se até o local, outros indivíduos tenham subtraído a fiação e a deixado apenas para o transporte.

Além desses indícios, existe outro forte indício, que é a existência de processos em andamento e/ou a pretérita condenação dos réus pela prática de crimes contra o patrimônio o que, embora por si só não possa ser considerado como prova, fortalece a convicção judicial. Já decidiram nossos tribunais:

PENAL E PROCESSUAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RÉU REINCIDENTE NA POSSE DE SIGNIFICATIVA QUANTIDADE DE DUAS ESPÉCIES DE ENTORPECENTES. INDICATIVOS DE PRÁTICA CONTINUADA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA EVIDENCIADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. (...). 2. Na hipótese dos autos, as instâncias ordinárias concluíram que o fato que ensejou o flagrante não constituiu evento isolado na rotina do recorrente, quer em razão da diversidade e da quantidade de drogas apreendidas (11g de cocaína, fracionada em 19 porções e 29g de maconha, fracionada em dois invólucros), quer em

razão de ele ser reincidente específico, circunstâncias essas que formam indicativo de prática de traficância de forma continuada, a evidenciar a sua periculosidade social, o que é suficiente para justificar a segregação para o fim de garantir a ordem pública, prevenindo-se, assim, a provável reiteração delitiva. 3. Recurso ordinário desprovido. (RHC 64.919/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 19/11/2015, DJe 09/12/2015)

ANTECEDENTES CRIMINAIS - Utilização como prova - Impossibilidade:14(b) - Os antecedentes do acusado não constituem prova; contudo, inequívoca e capitalmente, reforçam convicção, quando evidenciam que o ato incriminado nada mais é do que rotina em seu proceder. (Apelação nº 1.035.97/8, Julgado em 03/02/1.997, 12ª Câmara, Relator: - Junqueira Sangirardi, RJTACRIM 34/69)

ANTECEDENTES - Influência na fixação do escarmento - Ocorrência: 12(a) - Os antecedentes não constituem prova suficiente à expiação, mas fortalecem o convencimento judicial e influem na fixação do escarmento, por expressa previsão legal. RJDTACRIM VOLUME 28 OUTUBRO/DEZEMBRO/1995 PÁGINA: 39 RELATOR: - RENATO NALINI.

PROVA - Maus antecedentes - Valor: 30(d) - Os antecedentes negativos não servem de base exclusiva para decreto condenatório mas constituem importante adinículo para a formação do convencimento. (Apelação nº 1.171.909/6, Julgado em 03/02/2.000, 7ª Câmara, Relator: Corrêa de Moraes, RJTACRIM 47/133)

A respeito da prova indiciária, nesse sentido é o entendimento da doutrina: "A prova da autoria não se faz apenas por confissão espontânea ou por declaração das testemunhas, mas, muitas vezes, com base em prova meramente indiciária. Constitui erro crasso, como diz Mestre Frederico Marques, citando Vito Gianturco, o afirmar-se de que nenhuma presunção, por mais veemente que seja, dará lugar à condenação, pois tal assertiva equivaleria a abolir-se a prova indiciária do processo penal (MARTINS, Weber "O Furto e o Roubo no Direito e no Processo Penal - Forense - Rio de Janeiro - 1995 - p. 459).

Como já entendido por nossos Tribunais:

APELAÇÃO - RECEPÇÃO DOLOSA PROVA INDICIÁRIA E CIRCUNSTANCIAL - CONDENAÇÃO VALIDADE DA PALAVRA DOS POLICIAIS ABSOLVIÇÃO - Impossibilidade: Existindo provas indiciária e circunstancial concludentes, no que tange a existência da consciência da origem espúria do bem pelo agente, circunstâncias essas aliadas à palavra dos policiais que não teriam motivo algum para uma falsa inculpação, impossível de se cogitar a absolvição. Recurso não provido. (TJSP; Apelação Criminal 0000710-58.2011.8.26.0091; Relator (a): J. Martins; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Criminal; ANTIGO Foro Distrital de Brás Cubas - 2ª. Vara Judicial; Data do Julgamento: 28/08/2014; Data de Registro: 09/09/2014)

"O indício vale como qualquer outra prova e impossível o estabelecimento de regras práticas para apreciação do quadro indiciário. Em cada caso concreto, incumbe ao juiz sopesar a valia desse contexto e admiti-lo como prova, à luz do artigo 239 do Código de Processo Penal" (Ap.1070845/5, Rel. Renato Nalini, j. 06.10.1997, rolo 1132, flash 0194, fls.09).

PROVA - Presença de indícios concatenados - Ausência de prova direta que os desautorize - Validade - Entendimento:61 - Sendo a prova indireta mas segura, formada por indícios concatenados, sem contra-indícios ou prova direta que os desautorize, possível é a condenação nela baseada, mormente se a materialidade do delito é incontestada. RJDTACRIM VOLUME 16 OUTUBRO/DEZEMBRO/1992 PÁGINA: 133 RELATOR: - MARREY NETO

PROVA - Furto - Presença de indícios - Valor:182 - Sendo os crimes de furto praticados normalmente sem a presença de testemunhas, os indícios passam a ter

Verifica-se, também, que não há que falar-se em inimizabilidade em razão de consumo de substância entorpecente e/ou álcool. Primeiro, porque não comprovada. Segundo, porque a ingestão de bebida alcoólica, ou droga, só é excludente de culpabilidade se oriunda de fato culposo ou de força maior. Nesse sentido, o entendimento da jurisprudência:

DANO QUALIFICADO, DESACATO E LESÃO CORPORAL LEVE CIRCUNSTANCIADA, EM CONCURSO MATERIAL DE INFRAÇÕES. RECURSO DEFENSIVO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU ATIPICIDADE. SUBSIDIARIAMENTE, RECONHECIMENTO DA SEMI-IMPOTABILIDADE, COM REDUÇÃO DAS PENAS. Materialidade e autoria dos delitos bem demonstradas nos auto (...). SEMI-IMPOTABILIDADE PENAL. Não há que se falar em inimizabilidade ou em semi-impotabilidade da apelante, pois tanto o artigo 28, §§ 1º e 2º, do Código Penal, como os artigos 45 e 46 da Lei nº 11.343/2006, exigem, para a isenção ou redução da pena, que a embriaguez, pelo álcool ou substância de efeitos análogos, e a dependência ou o efeito de droga, sejam provenientes de caso fortuito ou força maior, e que o agente, em razão da embriaguez, dependência ou efeito de drogas, seja, ao tempo da ação ou omissão, inteira ou parcialmente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Já a embriaguez, voluntária ou culposa, como no presente caso, não exclui a imputabilidade penal (CP, art. 28, inciso II). Adoção legislativa da actio libera in causa, de modo que, se o agente deu causa à embriaguez voluntária (o agente quis se embriagar) ou culposamente (o agente não queria embriagar-se, mas por imprudência chega àquele estado), ele responde pelos atos praticados em estado de embriaguez. (...). (TJSP; Apelação Criminal 1500190-16.2019.8.26.0585; Relator (a): Gilda Alves Barbosa Diodatti; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Santo Anastácio - Vara Única; Data do Julgamento: 12/03/2020; Data de Registro: 13/03/2020)

APELAÇÃO FURTO QUALIFICADO. Preliminar de nulidade por cerceamento de defesa ante o indeferimento da realização de exame de dependência químico-toxicológica. Inocorrência. Ato justificadamente indeferido pelo magistrado no exercício de seu livre convencimento motivado - Mérito Materialidade e autoria comprovadas nos autos. Condenação mantida. Pleito de isenção de pena, com encaminhamento a tratamento adequado à dependência química, nos termos do art. 45, da Lei n.º 11.343/06. Descabimento. Dispositivo legal que exige comprovação da inimizabilidade ou prática do delito sob efeito de drogas em razão de caso fortuito ou força maior, o que não se verifica nos autos, não bastando a mera alegação de dependência química. (...). (TJSP; Apelação Criminal 0001976-42.2009.8.26.0288; Relator (a): Camilo Léllis; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Ituverava - 1ª. Vara Judicial; Data do Julgamento: 30/10/2014; Data de Registro: 03/11/2014)

APELAÇÃO CRIMINAL - roubo MAJORADO pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo - Recurso defensivo - Pretendida absolvição por insuficiência probatória - Impossibilidade - Materialidade e autoria delitivas sobejamente comprovadas nos autos - Reconhecimento efetivado pela vítima e confissão parcial dos acusados que, aliados aos demais elementos de convicção, dão a certeza do cometimento do delito - Inimizabilidade que não restou comprovada - Eventual atuação delitiva sob efeito ou dependência de droga que não decorreu de caso fortuito ou força maior - Condenação mantida - (...). (TJSP; Apelação Criminal 0053723-90.2014.8.26.0050; Relator (a): Camilo Léllis; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 12ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 07/06/2016; Data de Registro: 09/06/2016)

Referente a qualificadora do repouso noturno, resta caracterizada, tendo em vista ter o agente utilizado de período de menor vigilância da vítima.

1. Nos termos do § 1º do art. 155 do Código Penal, se o crime de furto é praticado

durante o repouso noturno, a pena será aumentada de um terço. 2. O repouso noturno compreende o período em que a população se recolhe para descansar, devendo o julgador atentar-se às características do caso concreto. 3. A situação de repouso está configurada quando presente a condição de sossego/tranquilidade do período da noite, caso em que, em razão da diminuição ou precariedade de vigilância dos bens, ou, ainda, da menor capacidade de resistência da vítima, facilita-se a concretização do crime. 4. São irrelevantes os fatos das vítimas estarem ou não dormindo no momento do crime, ou o local de sua ocorrência, em estabelecimento comercial, via pública, residência desabitada ou em veículos, bastando que o furto ocorra, obrigatoriamente, à noite e em situação de repouso. (TEMA 1144, STJ - Recursos Especiais n. 1.979.989/RS en. 1.979.998/RS)

No entanto, há que se analisar a recente Tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça – Tema 1087 (Recursos Representativos – REsp 1888756/SP, REsp 1890981/SP e REsp 1891007/RJ), delimitando que: “A causa de aumento prevista no § 1º do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4º)”.

Narra, ainda, o referido acórdão (REsp 1888756/SP):

“Assim, é razoável admitir a possibilidade de, diante das circunstâncias fáticas, a prática do furto durante o período de repouso noturno ser levada em consideração na dosimetria da pena. Em outras palavras, se a incidência da majorante no furto qualificado mostra-se excessiva, poderá ser utilizada como circunstância judicial negativa na primeira fase da dosimetria (art. 59 do CP). Nessa oportunidade, o órgão julgador avaliará, sob a ótica de sua discricionariedade, o elemento relativo ao espaço temporal em que a infração foi cometida, podendo, se assim considerar, analisar a circunstância judicial referente às circunstâncias do crime com maior reprovabilidade. Esse proceder possibilitaria calibrar a reprimenda de modo a atender o postulado da proporcionalidade diante do caso concreto”.

Assim, mesmo que a referida causa de aumento não possa ser individualmente aplicada, no presente caso, tendo em vista a ocorrência da qualificação no delito de furto, resta passível sua análise na primeira fase, como circunstância judicial.

Por fim, a consumação ocorreu em razão do bem ter saído da esfera de disponibilidade da vítima, pouco importando a recuperação posterior. RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO. MOMENTO CONSUMATIVO. POSSE MANSA E PACÍFICA DA RES FURTIVA. DESNECESSIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Ainda que ocorra a perseguição imediata do agente e se recupere a res, tem-se como consumado o delito de furto, com a anterior retirada da posse ou da propriedade do bem à vítima. Doutrina (evolução). 2. A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal é de que o crime de furto se consuma no momento em que o agente se torna possuidor da coisa subtraída, ainda que haja imediata perseguição e prisão, sendo prescindível que o objeto subtraído saia da esfera de vigilância da vítima. Jurisprudência do STF (evolução) 3. Recurso especial provido a fim de cassar a decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro para restabelecer a sentença penal condenatória proferida em primeiro grau. (REsp 1464153/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 03/02/2015)

Diante da robustez do conjunto probatório, a condenação do acusado pela prática de furto é medida de rigor.

Passo a dosar a pena.

Os réus Alessandro e Carlos possuem condenações anteriores transitadas em julgado, sendo que uma delas (fls. 98/102 e fls. 109/112) deve ser considerada na dosimetria da pena para a fixação da pena-base, como mau antecedente. A prática reiterada de crimes, por eles, indica a má formação da personalidade, sempre voltada à prática

de ilícitos criminais, antecedentes que impõem majoração da pena base como circunstância judicial. Relativo a Gabriel, em que pese ser tecnicamente primário, há que se analisar a existência de processos contra o patrimônio, em andamento, além da existência de atos infracionais (fls. 100/120 e fls. 122/123).

No mais, tratando-se de furto duplamente qualificado (rompimento de obstáculo e concurso) e, ainda, levando-se em conta a sua ocorrência durante o repouso noturno, o qual é valorado como circunstância judicial negativa neste caso, há maior reprovabilidade da conduta dos acusados, justificando a fixação da pena base acima do mínimo legal. Exaspero, por isso, a pena base em 1/3 (um terço), para Alessandro e Carlos, delimitando-as em 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, para cada um. E, exaspero a pena base, em relação a Gabriel, em 1/4 (um quarto), delimitando-a em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

O entendimento da doutrina é pela possibilidade de utilização de condenações distintas para avaliar maus antecedentes e para a agravante da reincidência: "Cumpra precisar que na hipótese de diversas condenações definitivas, uma valerá para majorar a pena-base, como maus antecedentes, e a outra para respaldar o aumento da reincidência, sem qualquer ofensa ao princípio do non bis in idem." (Flávio Augusto Monteiro de Barros, "Técnica de Aplicação da Pena", ed. Oliveira Mendes - APAMAGIS - Associação Paulista de Magistrados, 1997, p.3).

Não é diverso o entendimento da jurisprudência:

STJ, SÚMULA N. 241 - A reincidência penal não pode ser considerada como circunstância agravante e, simultaneamente, como circunstância judicial.

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. DESCABIMENTO. ROUBO. DOSIMETRIA. BIS IN IDEM. CONDENAÇÕES DIVERSAS UTILIZADAS PARA JUSTIFICAR OS MAUS ANTECEDENTES E A REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO. REINCIDÊNCIA E CONFISSÃO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. (...). 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não reconhece bis in idem quando condenações distintas são utilizadas para avaliar negativamente a circunstância agravante da reincidência e a circunstância judicial relacionada aos antecedentes criminais. 3. (...). 5. Habeas corpus concedido de ofício para redimensionar a pena, nos termos do voto. (HC 528.390/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 25/03/2020)

Na segunda fase, anoto que os réus Alessandro e Carlos são também reincidentes, circunstância agravante (artigo 61, I, do Código Penal), como comprovado pelas certidões de fls. 98/102 e 109/112. Acrescento à pena base, portanto, mais 1/6 (um sexto), pela reincidência, perfazendo um total de 03 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

Referente a Gabriel, considerando a circunstância atenuante (art. 65, inc. I, do CP- menor de 21 anos), reduzo a pena de 1/6 (um sexto), fixando-a em 02 (dois) anos e 01(um) mês de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

À míngua de circunstâncias agravantes ou atenuantes a serem consideradas, torno a pena definitiva.

O dia-multa é fixado no piso.

O regime inicial de cumprimento da pena relativo a Alessandro e Carlos é o fechado em razão de serem os réus reincidentes, além do fato de que contam com circunstâncias judiciais desfavoráveis.

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. FURTO QUALIFICADO TENTADO. PRETENSÃO DESCLASSIFICATÓRIA PARA FIGURA TÍPICA BÁSICA. IMPOSSIBILIDADE. COMPATIBILIDADE DO DELITO QUALIFICADO COM A CAUSA DE AUMENTO DE PENA REFERENTE AO

REPOUSO NOTURNO. REGIME INICIAL FECHADO. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I - (...). IV - Com efeito, "é pacífica nesta Corte Superior a orientação segundo a qual a fixação de regime mais gravoso do que o imposto em razão da pena deve ser feita com base em fundamentação concreta, a partir das circunstâncias judiciais dispostas no art. 59 do Código Penal - CP ou de outro dado concreto que demonstre a extrapolação da normalidade do tipo" (HC n. 452.147/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 14/08/2018). Na hipótese em foco, nota-se o delineamento de elementos concretos para a imposição de regime mais gravoso - os maus antecedentes, a reincidência e outras duas condenações definitivas a indicar a reiteração delitiva -, não se restringido a fundamentação a considerações vagas e genéricas relativas à gravidade abstrata do crime. Precedentes. Habeas corpus não conhecido. (HC 509.594/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/06/2019, DJe 11/06/2019)

Os réus Alessandro e Carlos não poderão apelar em liberdade, por serem reincidentes. Além disso, os réus encontram-se presos por força de prisão em flagrante delito, o que demonstra que sua custódia é necessária para a garantia da ordem pública. Ainda, por serem reincidentes, não fazem jus à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, ou qualquer outro benefício, por lhe faltar o requisito da suficiência, ex vi legis. Apelação criminal. Furto. Reincidência. Furto privilegiado. Pena privativa de liberdade. Substituição. Penas restritivas de direitos. A reincidência específica faz inviável falar-se em furto privilegiado ou em substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos. (TJSP; Apelação Criminal 1500146-79.2018.8.26.0569; Relator (a): Sérgio Mazina Martins; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Itu - 1ª Vara Criminal e de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher; Data do Julgamento: 24/07/2020; Data de Registro: 24/07/2020)

Por fim, relativo ao réu Gabriel, o regime inicial de cumprimento da pena é o aberto. E, por ser tecnicamente primário, poderá apelar em liberdade.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal condenar os réus CARLOS HENRIQUE BENTO DE OLIVEIRA e ALESSANDRO DA SILVA RODRIGUES FERRO às penas de 03 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, no regime inicial fechado, e 15 (quinze) dias-multa, no piso, cada um, como incursos no artigo 155, § 4º, incisos I e IV, do Código Penal. Recomendem-se os réus na prisão onde se encontram.

E, para condenar o réu GABRIEL RODRIGUES GEA à pena de 02 (dois) anos e 01 (um) mês de reclusão, no regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, no piso, como incurso no artigo 155, § 4º, incisos I e IV, do Código Penal. Nos termos dos artigos 43 e seguintes, do Código Penal, em especial os incisos I e IV, do art. 43, converto a pena privativa de liberdade em duas restritivas de direito, na forma de prestação de serviços à comunidade, por igual período ao da pena privativa de liberdade, a ser definida pelo Juízo das Execuções, e em prestação pecuniária, no valor de 01 (um) salário mínimo, em favor de entidade filantrópica do Município.

Por fim, considerando serem os réus assistidos pela defensoria pública, presumindo-se a insuficiência de recursos, isento-os das custas.
P. I. C.

Americana, 21 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA